

1500611-20.2022.8.26.0417
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: VICTOR GAVAZZI CESAR
Comarca: Paraguaçu Paulista
Foro: Foro de Paraguaçu Paulista
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... 03/03/2009; Data de registro: 08/04/2009).

TRÁFICO DE DROGAS - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente - Posse para uso próprio - Quantidade pequena de droga que exige prova concreta de que se destinava à entrega para terceiros para comprovar o delito de tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paraguaçu Paulista
Foro de Paraguaçu Paulista
3ª Vara
Avenida Siqueira Campos, 1429, . - Vila Affine
CEP: 19700-000 - Paraguacu Paulista - SP
Telefone: (18)3361-2844 - E-mail: paraguacu3@tjsp.jus.br

1500611-20.2022.8.26.0417 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500611-20.2022.8.26.0417
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME HENRIQUE FRANCESCHINI DE SOUZA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VICTOR GAVAZZI CESAR

Vistos.

GUILHERME HENRIQUE FRANCESCHINI DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim como no art. 129, caput, e no art. 329, caput, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 69 deste último diploma legal.

De acordo com a denúncia, na tarde de 18 de julho de 2022, por volta das 14h10min, na rua Faustino Dias Paião nº 327, neste município e comarca, o réu, trazia consigo e guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 2,79g de cocaína, na forma de uma pedra de crack, droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 26/27) e laudo de constatação provisória (fls. 71/73) e definitivo da droga (fls. 77/83).

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima indicadas, o

réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência praticada em detrimento dos policiais civis Lucas Henrique Lima Pedrozo, João Rafael Spoladori, Caio Biroli Russo e Matheus Hotsuta Nascimento, funcionários competentes para executá-lo.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o réu ofendeu a integridade física e corporal do policial civil João Rafael Spoladori, causando-lhe lesões corporais.

Recebida a denúncia, o réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Afastada a absolvição sumária, procedeu-se à instrução processual, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Após, Ministério Público e Defesa apresentaram seus memoriais escritos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, resistência e lesão corporal.

Registre-se, de início, que o processo transcorreu normalmente, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. Ademais, não se vislumbram quaisquer questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

Deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da pretensão acusatória, passo ao exame do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão acusatória é parcialmente procedente.

No tocante aos crimes de resistência e lesão corporal dolosa, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/06), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 144/145), bem como pela prova oral produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inconteste, recaindo sem pairar dúvidas sobre o acusado. Vejamos.

Em Juízo, o Policial Civil LUCAS HENRIQUE LIMA PEDROSO relatou, em síntese, que, por ocasião dos fatos, ele e outros policiais civis tinham se dirigido até a residência da namorada do réu Guilherme para o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. O réu estava no local e resistiu à abordagem policial com chutes, socos e cotoveladas contra ele e os demais policiais civis que tentaram contê-lo. Disse que a irmã e o genitor de Guilherme chegaram no local e ataçaram um cachorro para atacá-los, contexto em que foi mordido pelo animal. Asseverou que, para se defender do ataque, efetuou disparos de arma de fogo contra o animal, matando-o. Esclareceu, por fim, que a busca e apreensão domiciliar visava a averiguação de suposta participação do réu em um crime de roubo.

Por seu turno, o Policial Civil JOÃO RAFAEL SPOLADORI relatou que, durante a ação

policial que visava o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da namorada do réu, avistou Guilherme entregando algo para Luís Conessa, momento em que ele e o Policial Civil Caio Birolí Russo resolveram abordá-lo. Disse, porém, que o réu resistiu ao ato com violência e, desse modo, conseguiu se desvencilhar e empreender fuga do local. Asseverou que, durante a fuga, o réu jogou no chão o seu aparelho de telefonia celular, além de uma pedra de crack e invólucros utilizados para embalar drogas. Disse que, após breve perseguição, alcançou o réu que novamente resistiu à abordagem com violência, contexto em que a irmã e o genitor de Guilherme ataçaram um cachorro para atacá-los. Consignou que, em razão da violência perpetrada pelo réu, sofreu escoriações pelo corpo. Por fim, esclareceu que a ação policial visava à apuração de suposto crime de roubo praticado por Guilherme e que, por ocasião da abordagem, não viu o que o réu entregou para Luís Conessa, não podendo afirmar que era droga.

No mesmo sentido, foram as declarações do Policial Civil CAIO BIROLI RUSSO, que consignou não ter visto o réu entregar algo a Luís Conessa, pois a abordagem a Guilherme se iniciou antes de isso ocorrer.

A testemunha protegida confirmou por seu depoimento a resistência do réu à prisão e as agressões por ele realizadas aos policiais civis que tentavam realizar tal ato.

Já a testemunha IRENICE MARIA BUENO contou que apenas presenciou o cachorro atacando os policiais, bem como o momento em que um dos policiais efetuou disparos de arma de fogo para cima. Contou também ter visto Guilherme deitado no chão.

As testemunhas LUIZ FELIPE ROMANO e GABRIEL HENRIQUE MEDEIROS se limitaram a fornecer relatos abonadores sobre a conduta do acusado.

Por fim, ao ser interrogado em juízo, o réu GUILHERME HENRIQUE FRANCESCHINI DE SOUZA sustentou que a droga encontrada em sua posse seria destinada ao consumo próprio. Quanto à abordagem policial, afirmou que foram os policiais que o teriam agredido.

Encerrada a instrução, denota-se que a prova é contundente no sentido de que o acusado ofendeu a integridade física do Policial Civil João Rafael Sapoladori, autoridade em exercício de sua função, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo pericial de fls. 144/145.

Estando as palavras da vítima e testemunhas absolutamente seguras, fortes, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios, solução é emprestar-lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade única de aceitação de seu teor.

Não se pode presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos agentes públicos.

Frise-se que os Policiais gozam de presunção de legitimidade no tocante aos atos decorrentes do exercício da função que desenvolvem, garantindo normal credibilidade aos seus depoimentos.

Nesse contexto, não existe dispositivo legal que vede aos agentes policiais servirem como testemunhas. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Assim, a atuação dos agentes públicos revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou

arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado.

Seria verdadeiro um contrassenso o Estado conferir-lhes atribuição para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse qualquer crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL (...) 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a reavaliação probatória. 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).

Por outro lado, embora tenham negado a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos demais elementos de convicção e provas, ficando isolada quando em cotejo com restante do acervo constante dos autos.

Percebe-se, nesse sentido, que o acusado foi incapaz de infirmar o restante do conjunto probatório, que lhe é contrário, não apontando motivos aptos motivar a prova oral colhida ao longo da instrução, deixando de oferecer justificativa plausível para os fatos narrados ou, ainda, apontar eventuais equívocos nas provas materiais produzidas.

Inviável, pois, a absolvição em relação ao crime de lesão corporal vez que a prova é francamente hostil ao acusado.

NO mesmo sentido, também restou sobejamente demonstrado que o acusado, ao ser abordado pelos Policiais Civis Lucas Henrique Lima Pedrozo, João Rafael Spoladori, Caio Biroli Russo e Matheus Hotsuta Nascimento, em regular cumprimento de mandado de busca e apreensão, externou reação violenta e absolutamente exagerada, apresentando-se exaltado e procurando se esquivar dos agentes, resistindo à busca pessoal.

Destarte, o delito de resistência restou configurado, tendo em conta que, em clara tentativa de se furtar à ação policial, o réu se exaltou e agiu de forma violenta contra os policiais, sendo necessário o uso de força física para contê-lo.

Assim, mediante violência, se opôs à execução de ato legal, ou seja, sua abordagem pessoal e prisão.

Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt, no crime de resistência o “bem jurídico protegido é a Administração Pública, especialmente sua moralidade e probidade administrativa. O tipo penal protege a autoridade e o prestígio da função pública. Tutela-se, na verdade, a normalidade do funcionamento da Administração Pública, sua respeitabilidade, bem como a integridade de seus funcionários; a essência mesmo da tutela penal não é em relação ao funcionário, e sim ao próprio ato funcional que se quer prestigiar, partindo-se da presunção, logicamente, da legalidade do ato. Não tendo base legal o ato resistido, não se pode falar em crime, pois a ausência dessa elementar torna a sua resistência uma conduta atípica”. (Tratado de Direito Penal, Vol. 5 - Parte Especial: Dos Crimes Contra a Administração Pública e Dos Crimes Praticados por Prefeitos, 6ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

Esclarece ainda o referido autor que “a conduta típica consiste em opor-se à execução de ato legal (a legalidade exigida é tanto a formal quanto a substancial), mediante violência (emprego de força física) ou ameaça (prenunciando a prática de um mal grave à vítima) a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. O crime de resistência, portanto, é composto dos seguintes elementos constitutivos: a) oposição ativa, mediante violência ou ameaça; b) a qualidade ou condição de funcionário competente do sujeito passivo ou seu assistente; c) legalidade do ato a ser executado; d) elemento subjetivo informador da conduta” (idem).

De rigor, portanto, a procedência da ação penal também nesse ponto, porquanto a prova produzida é contrária ao acusado, sendo inviável a absolvição.

Todavia, quanto a imputação da prática do crime de tráfico de entorpecentes, a prova dos autos não indica, de forma robusta e categórica, para a realização de nenhum ato de mercancia realizado pelo acusado.

Embora tenha sido apreendida, na posse de Guilherme, uma única pedra de crack, com peso de 2,79g, tal fato não é prova suficiente para amparar a sua condenação pelo crime de tráfico, quando dissociado de outros elementos de corroboração da imputação inicial, conforme bem salientado pelo próprio representante do Parquet.

Nota-se que nem mesmo os Policiais Civis responsáveis pela sua abordagem souberam esclarecer em Juízo se o réu, de fato, tentava entregar algo a terceira pessoa (o que, em tese, poderia indicar ato de mercancia) ou se a droga apreendida simplesmente caiu de suas vestes no momento da tentativa de fuga.

Portanto, conforme assente na jurisprudência, existindo fundadas dúvidas quanto à tipificação do fato como delito de tráfico de substância entorpecente e a quantidade de tóxico apreendido seja compatível, sugerindo que se trate de porte para uso próprio, deve o delito enquadrar-se na figura do artigo 28 da Lei 11.343/06:

"Apelação - Uso de substância entorpecente - Recorrente surpreendido por policiais militares tendo em seu poder porções de maconha - Materialidade e autoria demonstradas pelas provas coligidas, técnica e oral - Tráfico, contudo, não demonstrado - Recorrente que, embora negando a imputação, alegou no momento da prisão e em juízo que é usuário de drogas - Não foi, ademais, surpreendido realizando qualquer ato indicativo do proscrito comércio - Desclassificação de rigor - Recurso do Ministério Público improvido" (Apelação Criminal 0007687-49.1998.8.26.0050; Relator(a): Salles Abreu; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/03/2009; Data de registro: 08/04/2009).

TRÁFICO DE DROGAS - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente - Posse para uso próprio - Quantidade pequena de droga que exige prova concreta de que se destinava à entrega para terceiros para comprovar o delito de tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade - Acerto da decisão desclassificatória para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 - Recursos improvidos (TJ-SP - APR: 00027805820168260322 SP 0002780-58.2016.8.26.0322, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/05/2021)

Registre-se que a ínfima quantidade de drogas apreendida, também é absolutamente compatível com o uso, tal como alegado pelo réu, que inclusive mencionou que havia feito uso de substância análoga poucos instantes antes de sua abordagem.

Nesse contexto, incumbe à acusação provar de forma inequívoca a destinação

mercantil do entorpecente apreendido, ônus do qual não se desincumbiu.

A dúvida favorece o acusado, na medida em que a sentença penal condenatória somente pode se embasar em elementos concretos de prova ou prova cabal da ação delituosa, do que não se cogita na hipótese.

Neste contexto, inexistindo evidência da finalidade mercantil da droga, o crime deve ser desclassificado para o porte para uso próprio.

Destarte, com supedâneo no artigo 383 do Diploma Processual Civil, desclassifico a conduta imputada ao réu, descrita na denúncia, para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Conclui-se, portanto, que o réu era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo, motivo pelo qual deverá ser responsabilizado penalmente.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 5º, da Constituição Federal e ao critério trifásico estatuído no art. 68, do Código Penal.

Na primeira fase, atendendo às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima), observo que não há nada que desborde do esperado para essa espécie de delito, restando as penas fixadas em seus patamares mínimos.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a reincidência (condenação definitiva, cfr. F/A de fls. 78/80), agravo as penas em 1/6 (um sexto), fixando as penas intermediárias em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de resistência (art. 329, do CP).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, permanecendo as penas nos mesmos patamares anteriormente estabelecidos.

Tendo ambos os crimes sido cometidos em concurso material, aplico a regra contida no artigo 69, do CP e, após o somatório das penas, torno definitiva a pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, em estrita observância ao disposto no artigo 33, §2º, "b" do CP, considerando a reincidência do réu em crime doloso.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem a concessão de sursis, porque não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, especialmente a reincidência em crime doloso.

Deixo de realizar a detração, os termos do art. 387, §2º do CPP e 42 do CP, que deverá ser oportunamente verificada pelo juízo da execução.

Quanto ao crime de posse de drogas para uso próprio, observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta ainda a ínfima quantidade de entorpecente apreendida, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas, mormente considerando que respondeu parte do processo encarcerado preventivamente.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória contida ne

denúncia para CONDENAR o réu GUILHERME HENRIQUE FRANCESCHINI DE SOUZA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime semiaberto e advertência sobre os efeitos das drogas, pela prática dos crimes descritos nos art. 129, caput, art. 329, caput, ambos do Código Penal e 28, caput, da Lei nº 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (artigo 387, §1º do CPP), por não estarem presentes, nesse momento, os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), especialmente considerando o quantum e regime de cumprimento de penal fixados e o período que já se encontra preso cautelarmente.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do CPP), isentando-o, desde já, do seu pagamento, por estar assistido por Advogado Dativo.

Expeça-se certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado:

- a) Oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação;
- b) Oficie-se ao TRE, para os fins do inciso III, do artigo 15 da Constituição Federal;
- c) Expeçam-se as guias e ofícios necessários para a execução da pena imposta.
- d) Cumpridas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Paraguacu Paulista, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA